

1501059-31.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... da atenuante da confissão e o tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão às fls. 14, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 15, pelos laudos de exame químico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501059-31.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501059-31.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267682/2021 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 20582718 -

DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2267682 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL WILLIAN SILVA GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

ISRAEL WILLIAN SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 30 de setembro de 2021, às 14h40min, na Rua Osvaldo Cruz, 145, Vila Esperança, nesta Cidade e Comarca de Bragança Paulista, o acusado trazia consigo e guardava, para comercialização, 14 (catorze) pedras de crack, pesando 4 gramas, 5 (cinco) porções de maconha, pesando 22 gramas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 10,00 (dez reais).

O Ministério Público, às fls. 102, requereu o aditamento da denúncia para constar a

causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista o laudo pericial de fls. 96/98, que constatou que o crime de tráfico de entorpecentes foi cometido nas imediações do estabelecimento de ensino Escola Estadual Silvío de Carvalho Pinto Junior (283 metros) e da Praça Irmã Lucilda (106 metros).

Tendo o acusado constituído defensora (fls. 48/55), foi dado por notificado (fls. 88) e ofereceu defesa prévia às fls. 110/118, juntando documento de fls. 119.

Após, a denúncia e o aditamento foram recebidos às fls. 124/125 e às fls. 130.

Manifestação do acusado a fls. 142, juntando documento de fls. 143.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação. Após, o réu foi interrogado (fls. 144).

Encerrada a instrução, os debates foram orais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a procedência da ação. Manifestou-se acerca da dosimetria da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, absolvendo-se o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes. Por fim, em caso de eventual condenação, manifestou-se acerca da dosimetria da pena, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão e o tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão às fls. 14, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 15, pelos laudos de exame químico toxicológico (fls. 90/95), que apontaram resultados positivos para maconha e cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, bem como pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, por sua vez, restou comprovada.

Na fase policial, o acusado confessou a prática delitativa. Disse que estava na posse das drogas apreendidas, afirmando que seriam para comercialização. Afirmou que era o seu primeiro dia no tráfico de drogas, relatando que estava passando por dificuldades financeiras. Disse que tentou arrumar um emprego, mas não conseguiu, o que o motivou a entrar na atividade ilícita de tráfico de entorpecentes, afirmando que estava arrependido de sua atitude (fls. 08).

Em juízo, negou a prática delitativa. Disse que a droga que estava na sua boca era para o seu uso, afirmando que eram 6 (seis) pedras de crack. Negou a propriedade das drogas no maço de cigarros. Disse que estava com R\$ 9,00 (nove reais) no bolso, sendo uma nota de R\$ 5,00 (cinco reais) e duas notas de R\$ 2,00 (dois reais).

Confirmou que acharam buchas de maconha na sua residência, que eram para o seu uso. Não conhecia os policiais. Sobre o seu depoimento na Delegacia, afirmou que ficou com medo e, por isso, concordou com o que eles lhe diziam. Não é mais usuário de drogas. Negou ter autorizado a entrada dos policiais na sua residência. Disse, por fim, que foi até o local dos fatos para comprar drogas, aproveitando-se para usar os entorpecentes ali no local. Afirmou que no local também havia um menor, que foi liberado.

Ademar Costa Júnior, policial civil, declarou que receberam uma denúncia de tráfico de drogas indicando o local como sendo bem ao lado do campo de futebol. Foram até o local, de viatura descaracterizada. De pronto, avistaram um indivíduo e resolveram fazer a abordagem. Localizaram 6 (seis) pedras de crack, dentro da boca do réu. O depoente também viu o momento em que o réu dispensou um maço de cigarros, no qual também foram encontradas mais 7 (sete) pedras de crack. O indivíduo não era conhecido dos meios policiais, tendo dito que estava passando por dificuldades financeiras. Questionado se havia mais drogas, confirmou que tinha mais um pouco em sua casa. Foram até o local, encontrando 5 (cinco) porções de maconha. Relatou que na denúncia só indicaram o local, não passando informações sobre o traficante.

Disse que dentro do campo de futebol é um local conhecido pela venda de entorpecentes. Confirmou que o réu confessou informalmente os fatos. Não presenciou nenhum ato de venda de entorpecente. Disse que o réu autorizou a entrada dos policiais na residência e acompanhou toda a diligência. Por fim, recorda-se de que

o réu possuía o valor de R\$ 10,00 (dez reais), sendo apenas uma nota, que seria referente a venda de uma pedra de crack.

No mesmo sentido o policial civil Pedro Henrique Miotto Kawakami. Acrescentou que receberam muitas reclamações sobre o local dos fatos, afirmando o que o local passou a ser uma "biqueira". Durante a abordagem, percebeu que o réu estava guardando algo na boca, encontrado drogas. Também foi localizado um maço de cigarros com mais drogas. O réu não tentou empreender fuga, afirmando que estava passando por dificuldades e que teria começado naquele dia a vender entorpecentes. Foram até a casa do réu, na qual encontraram buchas de maconha, tendo o acusado dito que era para seu consumo. Foram até o local após receberem uma denúncia. Disse que o réu estava sozinho. Não conhecia o réu. Sobre o maço de cigarros, foi localizado pelo seu parceiro. Disse que há escolas nas proximidades. O réu tinha R\$10,00 em sua posse, não se recordando do local em que estava. Não visualizou nenhuma venda de entorpecentes. Confirmou, por fim, que o réu autorizou o depoente e o seu parceiro a entrarem na residência e acompanhou a diligência. Pela prova oral produzida, verifica-se que a autoria do crime de tráfico restou comprovada.

Inicialmente, anoto que quanto aos depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção relativa de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela Defesa.

Ademais, nada indica que os policiais tenham criado alguma situação para acusar falsamente o acusado, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a implantação de drogas.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita." (RTJ68/64).

E ainda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (HC nº 74.608-SP/STF).

No caso dos autos, os policiais, após receberem denúncias da venda de entorpecentes no local, dirigiram-se ao ponto indicado e avistaram o acusado em atitude suspeita. Os policiais fizeram a abordagem e identificaram que o acusado estava com algum objeto dentro da boca, pela dificuldade de fala, localizando 6 (seis) pedras de crack.

Durante a abordagem, um dos policiais presenciou o réu dispensando um objeto, sendo encontrado ao seu lado um maço de cigarros com mais 7 (sete) pedras de crack.

O réu também possuía uma nota de R\$ 10,00 em seu bolso.

Indagado, o réu confessou informalmente a venda dos entorpecentes, afirmando que estava passando por dificuldades financeiras, sendo o seu primeiro dia na venda de drogas. O acusado, ainda, indicou que havia mais drogas em sua residência e conduziu os policiais até o local, autorizando a entrada e acompanhando toda a diligência, sendo encontradas mais 5 (cinco) buchas de maconha.

Assim, comprovada a propriedade da droga por parte do réu, resta analisar a sua finalidade e a outra conclusão não se chega senão a finalidade mercantil.

Com efeito, as circunstâncias do ocorrido, com denúncia anônima recebida, da atitude suspeita do acusado, bem como o fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas, além da variedade de drogas localizadas (auto de exibição e apreensão de fls. 14), e o dinheiro encontrado sem comprovação da sua licitude, comprovam a sua finalidade mercantil.

Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Assim, a versão dada pelo réu em juízo não restou comprovada nos autos, pois os policiais foram firmes e coesos em narrarem o ocorrido, tendo dito, inclusive, que a abordagem foi tranquila, tendo o réu confirmado a traficância no local. A confissão, inclusive, foi reiterada perante a D. Autoridade Policial (fls. 08), tendo o acusado se declarado usuário somente em juízo, com o nítido propósito de afastar a sua responsabilidade penal.

Também não há que se falar em desclassificação para o crime do artigo 28 da lei de Drogas, já que a alegação de vício não tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como é sabido, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

Dessa forma, imperiosa, pois, sua condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mais, fica afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.

Como se observa nos autos, o acusado foi abordado na rua e, apesar da proximidade do local com a Escola Estadual Silvío de Carvalho Pinto Junior e com a Praça Irmã Lucilda, conforme o laudo pericial de fls. 96/98, não restou comprovado que o tráfico foi praticado nas dependências ou imediações destes locais.

Ressalto que a causa de aumento visa coibir com maior rigor a venda da droga nestes locais em razão da maior aglomeração de pessoas, facilitando a disseminação da mercancia.

No caso em tela, porém, é certo que as testemunhas disseram que o réu estava sozinho no local, nada esclarecendo sobre eventual movimentação de pessoas decorrentes da escola e da praça.

Nesse sentido:

"Porém, a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada. O fato de haver escola, praça pública e campo de futebol nas imediações do local onde foi apreendido o entorpecente, por si só, não tem o condão de majorar a pena do acusado. Teria de haver prova de que o réu estava se valendo dessa proximidade para vender drogas aos frequentadores desses locais, o que não ficou demonstrado nos autos" (Apelação nº 0001050-57.2014.8.26.0362;

Relator (a): Augusto de Siqueira; Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 13/08/2015; Data de registro: 14/08/2015).

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Ainda na primeira fase, não há que se falar em aumento em razão da quantidade/variedade das drogas, pois apesar da sua variedade, a quantidade não é significativa a justificar o aumento nessa fase, totalizando 26 gramas de entorpecente.

Na segunda fase, verifico que se trata de réu com idade inferior a 21 anos na data do fato, mas impossível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há que se falar em atenuante da confissão, já que esta ocorreu apenas em solo policial. Somente a confissão judicial pode beneficiar o acusado.

Na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsume-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa), motivo pelo qual ele faz jus à redução de 2/3.

Assim, estabeleço a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º,

§ 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de drogas, que nos termos do laudo pericial pesavam aproximadamente 26 gramas, na posse de indivíduo primário, com idade inferior a 21 anos, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e a primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra ISRAEL WILLIAN SILVA GONÇALVES, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, CONDENA-LO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, substituída nos termos acima deliberados. Em razão da pena imposta, poderá o réu recorrer em liberdade.

Tendo em vista que a quantia em dinheiro apreendida é produto de crime (fls. 79), decreto o seu perdimento em favor da União, expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 11 de março de 2022.

Simone Rodrigues Valle
Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA